

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1729/2532

พนักงานอัยการจังหวัด ราชบุรี  
นางสุนีย์ พรหมชนะ

โจทก์  
กับพวก

ป.อ. มาตรา , มาตรา 84, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา , มาตรา 75, มาตรา 76

โจทก์กล่าวในฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน แต่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 มิได้ร่วมจำหน่ายกัญชาด้วย เพียงแต่ จำเลยที่ 2 ได้ บอกที่ ซ่อน กัญชาและขอให้จำเลยที่ 1 ช่วย จำหน่ายกัญชาแทนในขณะที่จำเลยที่ 2 ไม่อยู่ จึงเป็นการก่อให้เกิดจำเลยที่ 1 กระทำผิด อันเป็นความผิดฐาน เป็นผู้ใช้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ซึ่ง ถือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่าง กับ ข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง จะลงโทษจำเลยที่ 2 ฐาน เป็นผู้ใช้ ให้กระทำผิด ไม่ได้

การที่จำเลยที่ 2 ซึ่ง เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ได้ บอกที่ซ่อน กัญชา และขอให้จำเลยที่ 1 ช่วย จำหน่ายกัญชาแก่ผู้ซื้อแทนนั้น เป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 1 กระทำผิด เป็นความผิดฐาน เป็นผู้สนับสนุนตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ซึ่ง ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยที่ 2 ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีกัญชาเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗, ๘, ๒๖, ๗๕, ๗๖, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑ คดีขอบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ ๒ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗, ๘, ๒๖, ๗๕, ๗๖ ที่แก้ไขใหม่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑ เรียงกระทงลงโทษฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุกคนละ ๒ ปี ฐานจำหน่ายกัญชาจำคุกคนละ ๒ ปี รวมจำคุกคนละ ๔ ปี จำเลยที่ ๑ รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำเลยที่ ๒ รับสารภาพชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ จำเลยที่ ๑ จำคุก ๒ ปี จำเลยที่ ๒ จำคุก ๓ ปี ธนบัตรของกลางคืนเจ้าของ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง, ๗๖ วรรคสอง ลดโทษให้จำเลยที่ ๒ หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก จำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๒ ปี ๘ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๒ ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหาร กัญชาของกลางทั้งหมดเป็นของจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๒ ได้ขอให้จำเลยที่ ๑ ช่วยขายให้ในขณะที่จำเลยที่ ๒ ไม่อยู่ที่ร้านอาหาร โดยบอกที่ซอห์นกัญชาให้ทราบด้วย การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงเป็นความผิดฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยที่ ๒ ฐานเป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ ๑ จำหน่ายกัญชานั้น เห็นว่า ขณะจำเลยที่ ๑ ขายกัญชาให้กับผู้มาล่อซื้อในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ ๑๓ นาฬิกา จำเลยที่ ๒ มิได้อยู่ในร้านอาหาร แต่ได้ออกไปซื้ออาหารที่ตลาดแม่กลอง และกลับมาถึงบ้านเวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา จำเลยที่ ๒ จึงมิได้เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ ๑ จำหน่ายกัญชาแต่การที่จำเลยที่ ๒ บอกที่ซอห์นกัญชาและสั่งให้จำเลยที่ ๑ ช่วยขายแก่ผู้มาล่อซื้อถือเป็นการก่อให้จำเลยที่ ๑ กระทำความผิดอันเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้ตามประมวลกฎหมายมาตรา ๘๔ กรณีเช่นนี้จะลงโทษจำเลยที่ ๒ ฐานเป็นตัวการร่วมจำหน่ายกัญชาไม่ได้ เพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาเป็นการแตกต่างจากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญอย่างมากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรคสอง แต่การที่จำเลยที่ ๒ บอกที่ซอห์นกัญชาแก่จำเลยที่ ๑ ทั้งขอให้ช่วยขายให้เมื่อมีลูกค้ามาซื้อนั้น ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ ๑ กระทำความผิด อันเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ ด้วย ซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยที่ ๒ ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ จำคุก ๑ ปี ๔ เดือน รวมกับโทษฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

ตามที่ศาลอุทธรณ์กำหนดไว้แล้วเป็นจำคุก ๓ ปี ๔ เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒ ปี ๒ เดือน ๒๐ วัน นอกจากนี้แก้ไข  
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นายสำราญ สุชาติพงศ์  
ศาลอุทธรณ์ - นายประเสริฐ ศรีสุข

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |